

1000044-27.2019.8.26.0619

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Dano ao Erário

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos".

Mais a frente pontua: De forma geral, a improbidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará caracterizada sempre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga - SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000044-27.2019.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000044-27.2019.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Dano ao Erário

Requerente:

Justiça Pública

Requerido:

Fulvio Zuppani e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de FULVIO ZUPPANI e SEVEN LEILÕES JUDICIAIS ASSESSORIA S.S. LTDA, sustentando, em síntese, que por meio de denúncia anônima tomou conhecimento de que o patrimônio público estaria sendo dilapidado, em razão da venda de veículos automotores pertencentes à frota do município de Taquaritinga por preço abaixo do valor de mercado/avaliação e sem qualquer justificativa. Asseverou que a segunda requerida fora contratada sem a realização de procedimento licitatório. Afirmou que a administração municipal anunciou que venderia diversos veículos automotores da frota pública, por preços abaixo do valor de mercado referenciado pela Tabela FIPE. Sustentou que não surgiram interessados com relação a alguns veículos, então a administração emitiu edital para segundo leilão, e reduziu drasticamente os valores dos veículos colocados à leilão. Asseverou, ainda, que a segunda requerida ficou responsável pela avaliação dos bens, e que contatados para apresentarem os laudos de inspeção dos veículos, limitaram-se a apresentar

seus valores, sem descrição detalhada das avarias existentes e sem o respectivo dimensionamento do valor da depreciação. Sustentou que a avaliação dos veículos deveria ter sido efetivada pela administração, contudo, na ocasião, deixou a cargo da segunda requerida que ainda seria remunerada à ordem de 5% das vendas concretizadas. Pontuou que a referida avaliação deveria ter indicado o estado do veículo, o que não foi realizado. Asseverou que a requerida Seven atribuiu a bel prazer o valor mínimo da arrematação dos veículos no âmbito do Leilão nº 01/16, ocorrido em 02.08.2016, sendo que em pouquíssimo tempo depois, sem o apontamento de nenhum fato novo, lançou o Leilão nº 02/16, em 20.09.16, reduzindo drasticamente o preço da arrematação e por consequência banalizando o patrimônio público. Asseverou que a segunda requerida, agindo apenas com intuito lucrativo, reduziu em mais de 50% o preço dos bens da primeira para a segunda avaliação, sem nenhum critério, acabando por aceitar lances irrisórios, que caracterizam preço vil. Afirmou que o primeiro requerido, então prefeito municipal, deixou de tutelar o patrimônio público. Sustentou que os réus praticaram ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso IV e VIII, da Lei nº 8.429/92. Pugnou pela condenação dos requeridos pela prática de improbidade administrativa e pela condenação do ressarcimento de R\$ 42.700,00, valor equivalente à diferença de preço entre a primeira avaliação e o valor da venda dos veículos. Juntou documentos (fls. 14/607).

Ordenada a notificação prévia, a requerida Seven Leilões apresentou defesa preliminar (fls. 628/632) sustentando, em suma, que à época dos fatos a venda dos veículos foi precedida de avaliação, sob a observância de critérios e normas técnicas. Asseverou que o avaliador era pessoa de vasta experiência no mercado e que os veículos foram vistoriados in loco. Aduziu que foram levadas em consideração, ainda, a depreciação e as condições gerais dos veículos. Afirmou que as avaliações foram apresentadas para aprovação da comissão de leilão, formada por membros nomeados pela Administração Municipal e posteriormente publicados através de portarias, seguindo os parâmetros estabelecidos na lei. Sustentou que não era a ré que estabelecia os valores mínimos para lance inicial e sim os membros da comissão de leilão, sendo certo que os bens não poderiam ser vendidos por valor inferior ao valor de avaliação aprovado pela comissão de leilão. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 633/669).

Por sua vez, os requeridos Fúlvio Zuppani e Município de Taquaritinga deixaram de se manifestar nos autos (fls. 670).

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da defesa preliminar (fls. 676/678).

A inicial foi recebida, determinando-se a citação dos requeridos (fls. 680/681).

A requerida Seven Leilões reiterou os termos da contestação apresentada (fls. 688).

O requerido Fúlvio Zuppani, por seu turno, apresentou contestação (fls. 700/708), sustentando, em síntese, que inexistiu qualquer intenção de causar dano ao erário público. Pontuou que a frota se encontrava totalmente desatualizada, com sérios problemas na parte mecânica, funilaria, pintura e instalação elétrica. Asseverou que a falta de licitação para contratação da empresa Seven Leilões restou suprida pela Portaria nº 061/2016, que nomeou os senhores Milton Ferreira Lima Junior, Carlos Alberto Olivério, Luciano Rebech Filho e Fabio Luiz de Gonzaga Hidalgo para acompanharem os leilões. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Houve réplica (fls. 713/721).

Sobreveio sentença de procedência (fls. 722/737), que foi atacada por recurso de Apelação, dado provimento para anular a sentença (fls. 978/984).

Saneado o feito, foram designadas provas pericial, oral e documental (fls. 1011).

Veio laudo pericial aos autos às fls. 1040/1065.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas sete testemunhas (fls. 1172/1173).

As partes apresentaram suas alegações finais (fls. 1182/1207, 1211/1214 e 1215/1234).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Encerrada a instrução, passo ao exame do mérito.

Ab initio, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Como é sabido, cabe ao juiz o exame e valoração judicial dos elementos probantes, em vista dos fatos expostos na inicial.

A prova pericial se realizou por via indireta, não havendo a necessidade de participação direta do Assistente Técnico da parte ré, que poderia, em querendo apresentar o seu parecer no feito.

A alegação de cerceamento de defesa revela basicamente, inconformismo ante as conclusões do laudo pericial.

Além do mais, a parte poderia ter arguido suspeição ou impedimento do expert, contudo não o fez na petição sob apreciação, certamente porque nenhum motivo tem para tanto.

Friso que a perícia técnica foi realizada por profissional habilitado e de toda confiança do Juízo.

Ademais, a simples discordância com o teor do laudo pericial não enseja a decretação de invalidade ou determina a realização de nova perícia, sendo que os elementos colhidos no processo serão analisados todos em conjunto nesse decisum. Assim, resta afastada a tese de cerceamento de defesa.

No mérito, o pedido é improcedente.

Em linha geral, a improbidade administrativa costumeiramente é definida apenas como forma de moralidade qualificada a que se submete e que se exige dos agentes públicos e dos particulares colaboradores.

A rigor, é conceito mais denso. Trata-se da conduta divergente das normas morais, da lei e/ou dos costumes, indicando desonestidade dolosa em relação aos procedimentos esperados da administração pública, aqui em sentido amplo.

Com mais propriedade, Marino Pazzaglini Filho define que "Numa primeira aproximação, improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos".

Mais a frente pontua: De forma geral, a improbidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará caracterizada sempre que a conduta administrativa contrastar qualquer dos princípios fixados no art. 37, caput da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade), independentemente da geração de efetivo prejuízo ao erário.

Apesar da Lei Federal que trata do tema datar de 1992 [Lei Federal 8.429/1992], o conceito último não é vago. Diz muito, sobretudo nos tempos atuais em que Brasil parece finalmente repudiar veementemente a vexatória situação de degradação moral em que os agentes públicos e particulares não raramente são surpreendidos.

Da abstração dos princípios às técnicas exemplificativas dos artigos 9 a 11 da Lei Federal 8.429/1992, tenho por improbidade administrativa como sendo a quebra qualificada dos princípios norteadores do agente honesto.

A Constituição Federal estabelece que:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"

Em regulamentação à matéria, a Lei nº 8.666/93 esmiúça a base principiológica do Direito Administrativo, a qual se encontra consignada no citado artigo 37, caput, do Texto Constitucional, segundo o qual a Administração Pública deve obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Outrossim, a Lei Federal 8.429/1992, mais do que punir enriquecimentos ilícitos e recuperar verbas desviadas, veio proteger os princípios basilares da Administração Pública, prevendo três espécies de atos de improbidade administrativa: 1- Aqueles que resultam enriquecimento ilícito (artigo 9º); 2- Os que causam prejuízo ao

erário (artigo 10) e 3- Aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11).

No ponto, vale trazer à baila os ensinamentos do professor e constitucionalista MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, relacionados a essa matéria, in verbis:

"Há três tipos de corrupção que, salvo melhor juízo corresponderia aos três grandes grupos de atos de improbidade administrativa definidos na Lei nº 8.429/92, a saber: a corrupção-suborno, Que é a corrupção por meio de retribuição material e que estaria configurada nas condutas do art. 9º, (atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento); a corrupção favorecimento, que é a corrupção que resulta do privilegiamento do privado em detrimento do público e que corresponde às condutas descritas no art. 10 (atos de improbidade que causam prejuízo ao erário); e a corrupção-solapamento, que atinge o próprio fundamento íntimo da legitimidade e que estaria consubstanciado nas fórmulas de conduta do art. 11 (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública)" (Revista de Direito Administrativo n. 185, p. 1, resumido por Márcio Lins Chila Freiesleben, in Revista Jurídica de Direito Privado - JUS 94, edição especial, n. 17, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - comentários à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992).

Estes princípios da Administração Pública têm como base o princípio da legalidade, sustentáculo de todo o regime jurídico administrativo e integrante do Direito Público como elemento indissociável na sua aplicação e na sua finalidade.

A esse propósito, destaca o Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO (Elementos de Direito Administrativo, 2ª edição, 1991) que:

"O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a qualquer tendência de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual irrompem, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia de soberania de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior esquema de poder assentado na relação soberano súdito(submisso)".

Também há de se destacar, porque relacionado com os fatos da demanda em apreço, o princípio da moralidade, o qual impõe a obrigatoriedade de o agente administrativo agir com honradez e dignidade na condução e no "trato dos assuntos que lhe são afetos", pois "por consideração de Direito deverá também decidir entre o honesto e o desonesto. Por consideração do Direito e da Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos" (Maurice Hauriou, Paris, pág. 197, por Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo).

Nesse diapasão, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que "o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo, mas por legalidade e legitimidade se entende não só a conformação do ato com a Lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo." (Revista de Direito Administrativo, 89/134).

A inserção do princípio da moralidade administrativa na Constituição Federal reflete a preocupação com a ética na Administração Pública, albergando esse valor juntamente com outro que se associa ao combate à corrupção e à impunidade praticadas no setor público.

Nesse contexto, "com a inserção do princípio da moralidade na Constituição, a exigência de moralidade estendeu-se a toda a Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as categorias de servidores públicos e a abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento ilícito" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 25ª edição, 2012, Editora Atlas, p. 880).

De outro giro, como é de conhecimento geral, a Lei nº. 14.230/21, publicada em 25 de outubro de 2021, promoveu relevantes alterações na Lei nº 8.429/92 que trata da prática de atos de improbidade administrativa, sanções e procedimento judicial.

Dentre as alterações implementadas, merece destaque especial para o caso em tela a supressão do ato de improbidade administrativa praticado mediante culpa, bem como a especificação realizada pelo artigo 1º, § 2º, da LIA que exige dolo específico do

agente para configuração do ato ímprobo, isto é, “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastante a voluntariedade do agente”.

A questão foi submetida a julgamento pelo C. STF nos autos do ARE 843989, afetado ao Tema 1199 da Repercussão Geral.

Recentemente, em 18 de agosto de 2022, o julgamento foi concluído e fixadas as seguintes teses:

- 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;
- 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
- 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposos, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

- 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Deste modo, ao caso em tela, aplicam-se as novas regras estabelecidas pela Lei nº.14.230/21, com exceção do novo regime prescricional.

Feitas as considerações essenciais, passo à demanda concreta.

Alega o autor que houve dispensa indevida de licitação para contratação da ré Seven Leilões, vejamos.

No que se refere a obrigatoriedade de realizar procedimento licitatório, o artigo 10, inciso VIII, da Lei de improbidade administrativa atual prevê:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva”

Assim, sempre que houver de um lado a Administração Pública, para qualquer contratação há a obrigatoriedade da licitação.

O dever de licitar decorre do princípio da isonomia que, no dizer de Celso Antônio “imperla e limita a liberdade não só do legislador que não pode instituir critérios ou discriminações arbitrárias, como também limita e regra o comportamento da Administração Pública. Aplicado o princípio da isonomia à Administração, significa que não se pode dar tratamento diferenciado a quem quer que seja, salvo se razões especiais autorizam a discriminação” (Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Ed. Revista dos Tribunais, 1978, p. 50).

Como ensina Franco e Gondo “a licitação é a regra. A exceção é a dispensa” (Concorrência Pública, 1969, p. 19).

Na mesma linha de raciocínio o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal estabelece que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

A licitação é a regra de observância imperativa, podendo haver seu “afastamento” na presença das hipóteses legais em que o certame não tem como ocorrer, fica facultada a sua realização ou é inviável, conforme os art. 17, 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, respectivamente.

Há uma variedade de situações em que a licitação é afastada indevidamente e segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a dispensa indevida da

licitação configura-se dano in re ipsa.

Existem julgamentos recentes (por exemplo, STJ, AgRg no REsp 1.288.585/RJ, de 16/2/16 e AgRg no REsp 1512393/SP) que entendem que a demonstração de dano financeiro efetivo não é necessária para a configuração dos atos de improbidade decorrentes de dispensa indevida de licitação. O dano seria in re ipsa, na medida em que o poder público, quando não promove a licitação, sendo ela obrigatória, deixa de contratar a melhor proposta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1º Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a dispensa indevida de licitação configura dano in re ipsa, permitindo a configuração do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Precedentes: AgInt no REsp 1.604.421/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.584.362/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018; AgInt no REsp 1.422.805/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018. 2. In casu, o Tribunal de origem concluiu que "dúvida não há de que a Lei 8.666/93 restou contrariada. Contudo, há que perquirir acerca da existência de ato ímprobo em tal conduta. Compulsando os autos, visualizo indícios veementes de que o procedimento licitatório foi forjado, inclusive, com erros grosseiros que saltam aos olhos. (...) As provas carreadas aos autos demonstram que os demandados contribuíram para fraudar licitação de aquisição de material para execução das obras objetos do Contrato de Repasse n. 2640. 0125308-45/2001 (SIAFI 437253) e do Convênio n. 3.380/2001, que visou fim proibido em lei, o que insofismavelmente acarretou a aplicação indevida dos recursos federais" (fls. 2.293 e 2.305). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1537057 / RN AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0131639-3 Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 09/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2019). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10 DA LEI 8429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A 2ª Turma do STJ possui entendimento no sentido de que a dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo ao erário in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, em razão das condutas dos administradores. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 178.852/RS, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/05/2013; REsp 817.921/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 06/12/2012. 2. Na hipótese dos autos, a análise da pretensão recursal, no sentido de rediscutir a razoabilidade ou proporcionalidade das sanções aplicadas, com a consequente reversão do entendimento exposto pela Corte a quo, exigiria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1512393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2015). Grifei. EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA DA EMPRESA CONTRATADA. PROVA DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, INACUMULATIVIDADE DE PENAS E IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO QUE FOI RECEBIDO CARENTES DE PREQUESTIONAMENTO. DISCUSSÃO DOS TEMAS NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. (...). A indevida dispensa de licitação, por impedir que a administração pública contrate a

melhor proposta, causa dano in re ipsa, descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema. Precedentes da Segunda Turma. 4. (...) (STJ - REsp: 817921 SP 2006/0026590-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012). Grifei.

A improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a máquina administrativa de nosso país. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção administrativa que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Constituição Federal.

O conceito de improbidade é bem mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si. É o contrário de probidade, que significa qualidade de probo, integridade de caráter, honradez. Logo, improbidade é o mesmo que desonestidade.

No caso dos autos, a contratação questionada pelo Ministério Público restou incontroversa.

Outrossim, é certo que a dispensa da licitação, no caso dos autos, realizando o Município a contratação direta de empresa de leilão para a alienação dos seus bens, implica prejuízo inerente a conduta (dano in re ipsa), conforme tem reconhecido o E. Superior Tribunal de Justiça.

De outro giro, segundo a inteligência do novo art. 1º da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230 de 25.10.2021, são puníveis somente as condutas dolosas.

Outrossim, o cerne da questão diz respeito a ser indevida ou não a dispensa de licitação havida quanto à determinação de encaminhar os veículos da Prefeitura para venda por meio de leilão através da empresa contratada.

Regra geral, todo contrato administrativo deve ser precedido de licitação, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal:

"Art. 37- (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Contudo, a própria Constituição, no dispositivo acima mencionado, previu a possibilidade de sua não realização, restando ao legislador ordinário enumerar as hipóteses cuja especificidade não é compatível com a formalidade, o custo e a demora de um procedimento licitatório.

Tais situações estão previstas de forma taxativa no artigo 24 e de forma exemplificativa no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, que versam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

No presente caso, não há nenhuma justificativa expressa para a dispensa da licitação.

Contudo, de acordo com as provas colhidas, os réus não agiram com dolo, e sim, com culpa grave.

Na qualidade de Chefe do Executivo à época, o requerido Fulvio, deveria conhecer a obrigatoriedade do procedimento licitatório na contratação de empresas privadas. Do mesmo modo, tratando-se de empresa especializada em leilões, a ré Seven Leilões, não há que se falar em ausência de culpa grave, quando beneficiada pela contratação dispensada de procedimento licitatório público, na forma do art. 37, XXI, da CF, e 2º da Lei nº 8.666/93.

Em que pese a regulamentação da atividade de leiloeiro disciplinada pelo Decreto nº 21.981 de 1.932, estabeleça regime de escala para a contratação de Leiloeiro pela União, Estados ou Municípios, é certo que, em razão de tratar-se de atividade privada, contraria os princípios constitucionais de isonomia, ampla competitividade e proposta mais vantajosa.

Neste aspecto, verifique-se a jurisprudência pátria sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – LEILOEIRO OFICIAL – CONTRATAÇÃO – DECRETO 21.981/32 – INSTRUÇÃO NORMATIVA/DREI 17/2013 – LICITAÇÃO – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. 1 –

Tendo em vista que o art. 37, XXI, da Constituição Federal, estabelece o procedimento licitatório como regra geral, há que prevalecer a determinação que traduza os reais intuitos da norma constitucional. 2 - O Decreto 21.981 e a Instrução Normativa/DREI 17/2013 preveem a possibilidade de cobrança de valores relativos a reembolsos de despesas havidas com leilão. (TJ - MG - AC: 10702130249346003 MG, relator Jair Varão, Julgamento 22/02/2018, publicação 14/03/2018). Grifei.

O art. 42 do Decreto n. 21.981/32, ao dispor que a administração pública pode contratar de forma direta o leiloeiro mais antigo, não foi recepcionado pela CF (art. 37, XXI) e é contrário ao ordenamento infraconstitucional vigente (Lei n. 8.666/93) (TJ - SC - AI: 0032897-82.2016.8.24.0000, Relator Joao Henrique Blasi, Julgamento 31.10.2017, segunda Câmara de Direito Público).

Com efeito, após uma leitura minuciosa dos inúmeros documentos que instruem a presente ação, sem sombra de dúvida, a postura do requerido Fulvio, então Prefeito de Taquaritinga, responsável pela lisura e transparência das contas públicas, deve ser reprovada, considerando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que fundam a Administração Pública.

Em Defesa, o requerido Fulvio, ouvido sob o crivo do contraditório, esclareceu que na época foi informado pelo departamento jurídico e de licitações que havia uma dispensa de licitação por se tratar de uma firma que já prestava serviço ao Estado e diversos município e por possuir leiloeiro oficial, além de se tratar de um leilão que poucos leiloeiros tiveram interesse. Disse que a contratação direta foi embasada em parecer jurídico e da comissão de licitação.

Vê-se, portanto, que o requerido Fulvio agiu com culpa, não restando demonstrada dolo em sua conduta.

Nas lições de Pontes de Miranda, "a culpa crassa, magna, nímia, como se dizia, que tanto pode haver no ato positivo como no negativo, é a culpa ressaltante, a culpa que denuncia descaso, temeridade, falta de cuidados indispensáveis. Quem devia conhecer o alcance do seu ato positivo ou negativo incorre em culpa grave"

(MIRANDA, Pontes de, . Tratado de Direito Privado, vol. XXIII, Rio de Janeiro, Borsói, 1958, p. 72. Apud CRUZ, Alcir Moreno da, e BORGES, Mauro. O artigo 28 da LINDB e a questão do erro grosseiro. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-mai-14/opinioao-artigo-28-lindb-questao-erro-grosseiro#_edn10. Acesso em 31.08.2022, às 16:47).

Contudo, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa trazida pela Lei Federal nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, impossível a condenação dos réus pela conduta culposa.

Em última análise, alega ainda o Ministério Público, que alguns veículos da frota municipal foram alienados a preço vil, o que ensejaria lesão ao erário, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei de Improbidade Administrativa.

Ainda que houvesse porventura lesão ao erário em decorrência dos fatos, como dito alhures, eles não foram praticados com dolo.

De mais a mais, no caso, não há parâmetros seguros nos autos quanto aos critérios de avaliação utilizados na primeira e segunda avaliação, onde foi imputado o subfaturamento, eis que são considerados diversos fatores para estimar as condições gerais do veículo.

Nessa senda, não se descuida, inclusive, como já ressaltado, que a legislação de regência exige a demonstração de dolo específico do agente ímprobo, isto é, vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas ex lege.

Considerando que se trata de ação de assento constitucional que tutela direitos difusos superiores da comunidade e/ou cidadania, ressalvados os casos de comprovada má-fé, por força legal (art. 23-B, § 2º, da LIA), não se impõe a condenação de custas, despesas e honorários de advogado. Logo, deixo de fixar qualquer sucumbência.

P.I.C.

Taquaritinga, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA